

1500261-68.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... os fatos, já conhecido como ponto de tráfico, onde permaneceu um tempo sozinho, em campana, tendo verificado um indivíduo em atitude típica de tráfico, porquanto veículos pararam, ele se dirigiu aos veículos, fez breve contato, voltou para a calçada, agachou, mexeu na calçada, retornou para o veículo, entregou algo e recebeu algo em troca. Então, acionou o policial André, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500261-68.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000203

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047558/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 23110280 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 18/22/594 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 2047558 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Aos 25 de agosto de 2022, às 14:20h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC FABIO GONÇALVES HILSDORF - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC ANDRE AUGUSTO PIRES - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, ante à ausência do réu, pela MM. Juíza foi dito: "DECRETO A REVELIA DO RÉU, que não compareceu à presente audiência mesmo tendo sido intimado, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 136/141". A seguir, foi colhido o depoimento da testemunha PC FABIO GONÇALVES HILSDORF.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC ANDRE AUGUSTO PIRES, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC ANDRE AUGUSTO PIRES, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 91/93. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 109), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 113/117), sendo a denúncia recebida (fls. 123/126). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi declarado revel. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, fotografia de fls. 14 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 66/68. A autoria é incontroversa. O policial civil Fabio Luís Gonçalves Hilsdorf, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, no dia dos fatos, realizando investigação de tráfico de drogas pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, em viatura descaracterizada, enquanto os demais policiais permaneceram pelas redondezas em viatura caracterizada. O depoente visualizou que um indivíduo, de estatura baixa, trajando camiseta regata com a cor predominante azul, boné e bermuda, posteriormente identificado como sendo o ora acusado, atendeu algumas pessoas que dele se aproximavam. Disse que o réu pegava algo homiziado na calçada próximo a ele e entregava ao interlocutor, recebendo dinheiro em contrapartida, conduta realizada por diversas vezes. Diante disto, o depoente entrou em contato com o policial André e transmitiu as características físicas, de vestimenta e o local onde o acusado se encontrava. Contou que o policial André localizou o réu no local dos fatos, em revista pessoal com ele nada de ilícito fora encontrado, porém localizou em um cano sete eppendorfs contendo substância aparentando ser cocaína. Indagado, o réu admitiu que estava traficando drogas, comercializando cada eppendorf pelo valor de dez reais, bem como que pegava para vender em kit com 12 eppendorfs e a após a venda de cada kit recebia um eppendorf para seu consumo. Narrou que o réu afirmou que não estava com dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, pois repassava a outro indivíduo que passava pelo local de bicicleta preta. Diante das circunstâncias, deram voz de prisão em flagrante ao réu e o conduziram à delegacia. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil André Augusto Pires, ouvido apenas na fase policial. O acusado, a seu turno, optou por tornar-se revel. Assim, tem-se que o crime restou cabalmente comprovado. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em

cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime de tráfico descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que o réu é tecnicamente primário. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presentes os requisitos legais, cabível o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, porém, ante a natureza do entorpecente apreendido, não em grau máximo. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Fabio, Policial Civil, declarou que estava com a viatura descaracterizada e foi até o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Efetou uma breve campanha e percebeu que um indivíduo baixo, de camiseta regata de cor azul, passava pelo local e se dirigia a alguns veículos que paravam. Ele também ia até um ponto em uma calçada, pegava um objeto e entregava às pessoas que passavam pelo veículo. Pegou as características do indivíduo e passou a seu parceiro, que abordou o acusado. Com ele, nada de ilícito foi localizado. Porém, no local para onde o réu se dirigia (um cano na sarjeta), foram achadas as drogas descritas na denúncia. O acusado confessou informalmente o tráfico de drogas e disse que ganhava uma porção em troca de efetuar a venda de um kit. Não foi achado dinheiro com o réu, porém, ele disse que entregava os valores da venda para uma pessoa que passava com uma bicicleta preta. O réu não compareceu à audiência designada para sua oitiva, todavia, sua ausência não pode ser tomada em seu prejuízo, haja vista que está inserida na autodefesa do acusado a opção por deixar de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, à semelhança do direito constitucional ao silêncio. No mais, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais

testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da suposta "movimentação suspeita" visualizada, não foram apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos, embora os próprios agentes mencionem que outras pessoas estavam no local. Ressalta-se, ainda, que as substâncias não estavam sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: "Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material;(...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a "integrar organização criminosa", é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida" (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 - grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário na época dos fatos; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal); (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:
" Vistos.

AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30, na Rua Dom Manoel, nº 1125, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Piracicaba, guardava e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) eppendorfs de cocaína em pó, pesando cerca de 8,6g (oito gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, já conhecido ponto de venda de drogas, utilizando também uma viatura descaracterizada, quando avistaram o réu em atividade típica de tráfico, porque, por reiteradas vezes, mantinha contato com pessoas que dele se aproximavam, pegava algo na calçada próximo de onde estava, entregava algo às pessoas e delas recebia dinheiro em troca. Em razão disso, os agentes da lei procederam à abordagem do réu e, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, em um cano localizado na calçada próximo de onde ele estava, os policiais localizaram sete eppendorfs de cocaína. Indagado, o réu confessou informalmente aos policiais que traficava no local, informando que recebia um kit com 12 eppendorfs de cocaína, vendia cada eppendorf pelo valor de dez reais e, após a venda de cada kit, recebia como pagamento um eppendorf para seu consumo.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 109) e apresentou defesa preliminar (fls. 113/117), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia e concedeu liberdade provisória em 20.04.2022 (fls. 123/126).

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia, prejudicado o interrogatório do réu, que se tornou revel.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, pela fotografia de fls. 14, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 66/68, que trouxe resultado positivo para cocaína, e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 09).

Em juízo, tornou-se revel.

De todo modo, a prova produzida é maciça e incriminadora.

O policial civil Fábio relatou que estava com viatura descaracterizada e se dirigiu ao local os fatos, já conhecido como ponto de tráfico, onde permaneceu um tempo sozinho, em campana, tendo verificado um indivíduo em atitude típica de tráfico, porquanto veículos pararam, ele se dirigiu aos veículos, fez breve contato, voltou para a calçada, agachou, mexeu na calçada, retornou para o veículo, entregou algo e recebeu algo em troca. Então, acionou o policial André, passando essas informações. Atestou que o indivíduo foi abordado e, com ele nada foi encontrado, mas, num cano na sarjeta, onde o réu acessava, encontraram sete porções de cocaína, tendo o réu confessado que vendia o entorpecente porque era usuário, esclarecendo que pegava um kit com doze porções, vendia onze e ficava com uma em pagamento, para seu uso. Asseverou que não havia dinheiro com ele e ele falou que entregava o dinheiro para uma pessoa que passava de bicicleta. Aduziu que realmente tinha perdido o réu algumas vezes de vista, quando ia até a calçada, sendo possível que tivesse entregado o dinheiro nesses momentos.

No mesmo sentido o depoimento do policial André, ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJ TJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem visualizado o acusado em atividades típicas de tráfico, pegando algo na calçada, entregando às pessoas que dele se aproximavam e recebendo algo em troca, vindo, logo em seguida, a abordá-lo e a localizar sete porções de cocaína no local que ele acessava, conduzem à certeza quanto a autoria e a destinação da droga ao comércio ilícito.

Anoto, para constar, que a quantidade de droga apreendida e a forma como estavam acondicionadas, aliadas ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, evidenciam mesmo a sua destinação ao tráfico.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Importa anotar, ainda, que o fato de não ter sido apreendido dinheiro em poder do acusado é irrelevante, eis que os policiais atestaram que ele confessou informalmente a traficância, revelando detalhes da movimentação do crime, inclusive, que repassava o dinheiro para um outro rapaz e que recebia uma porção de

cocaína para cada kit vendido, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova.

E o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena-base no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado. Assim, reduzo a pena fixada em dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja "suficiente".

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, por incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão a ser cumprido no regime aberto, e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo DEFENSOR foi dito que aguarda a intimação do réu acerca da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do Representante do Ministério Público, dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intime-se, por edital, o réu acerca da sentença proferida.

Após, tornem conclusos para deliberações.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]